

<제60회 민사소송법 시험 총평>

안녕하세요~ 객준형 변리사입니다.

지금까지 힘들고 긴 시간을 버텨오시고 큰 시험까지 치르시느라 정말 수고 많으셨습니다. 저도 아직까지 기득시험, 삼시시험을 마쳤을 때 모든 걸 쏟아내고 탈진했던 느낌이 생생합니다.

난이도부터 말씀드리자면, 올해 시험 난이도는 “중상” 정도라고 보여집니다.

[문제-1]의 설문(1) - 10점

[문제-2]의 설문(1), (2) - 20점

[문제-3]의 설문(1), (2), (3) - 30점

위 총 60점 분량의 문제들은 제가 실전GS A, B형 및 모의고사에 직접적으로 문제를 출제했던 것들이라 복습을 어느정도 하셨다면 비교적 무난하게 풀 수 있었을 것입니다.

다만, 문제 지문이 길었고 최신 判例가 다수 출제되었으며, 일부 지엽적인 논점도 함께 출제된 터라 긴박한 시험장에서의 체감난이도는 쉽진 않았을 것입니다.

또한, 문제가 어렵진 않더라도 답안을 제대로 써내는 것은 또 다른 문제이기 때문에 생각했던 것보다 막상 답안이 잘 써지지 않았을 수도 있습니다. 만약 평소에 논점 찾기는 잘했는데 시험에서 답안이 잘 써내려가지지 않고 벅찬 느낌이었다면(저도 기득때 이런 느낌이 있었습니다) 처음보는 문제에 대한 풀답안쓰기 연습을 조금 늘리실 필요가 있습니다. 목차만 잡는 것과 긴장된 상태에서 낯선문제의 풀답안을 쓰는 것은 차이가 있기 때문입니다.

문제별 구체적인 목차 및 해설은 아래의 문제별 답안을 참고 부탁드립니다.

다들 정말 수고 많으셨고 이제 다 끝났으니 한숨 돌리면서 푹 쉬시기 바랍니다. 결과와 무관하게 목표를 위해 최선을 다해 인생의 한 페이지를 채운 스스로를 대견하게 생각하시기 바랍니다.

언제든 문의사항이 있으면 mrtosilson@gmail.com 또는 메가변리사 QnA 게시판에 질문 주시면 답변드리겠습니다.

변리사 2차서술형시험은 1차객관식시험처럼 단순히 결론을 아냐모르냐로 점수가 갈리는게 아닙니다. 서술형 시험은 ox퀴즈가 아니죠.

1)긴 글로 된 문제의 주쟁점을 파악하고 2)결론으로 가기위한 논거를 잘 구성하는게 더 중요합니다.

이번시험의 설문 말미마다 “논거를 들어 설명하시오.”라는 문구가 삽입된 이유가 있는 것이지요.

흔히들 최대한 구석구석 모두 가져가야만 합격한다고 생각하지만 전혀 그렇지 않습니다.

이번 시험에서도 주된 논점들에 대해서도 제대로 잘 쓴사람이 그렇게 많지 않습니다.

주된 논점들만 제대로 잘 쓰는 법을 익히고 그외 지엽적인 부분은 “컴팩트하게 간단히” 준비해두거나 “알고있는 기본논점을 활용”해서 최대한 논리적으로 사실관계를 풀어내면 됩니다.

제가 늘 말씀드리는 내용입니다. 역사는 항상 반복되고 합격자들은 이를 잘 알고 있습니다.

아울러, 학원가의 잘못된 선동이나 광고에 휘둘리지 마시고 중심을 잡고 “내가 무엇을 어떻게 공부해야 시험에서 좋은 점수를 받고 합격할 수 있을지” 집중하고 정진하시기 바랍니다.

저는 항상 여러분이 고득점으로 합격하기 위해 알맹이로 채운 강의를 하며, 앞으로도 강의내용을 발전시키려고 노력할 것입니다.

<문제-1>

I. 설문(1) – 객준형 실전GS B형 8회 [문제-4] 출제

1. 문제의 소재

2. 탈퇴의 의의취지 및 요건

3. 전주가 탈퇴하지 않은 경우 전주와 참가인의 공동소송 관계

(1) 학판검

(2) 사안 – 합일확정 요청으로 필수적 공동소송 관계

4. 필수적 공동소송의 심리 방식

(1) 연합관계, 제67조

(2) 송중판상 일반론

(3) 사안 – 필수적 공동소송 관계에 있는 甲의 청구도 판단하였어야 하므로 1심판결 위법하고 상소로 당사자는 구제받음

5 사안해결

甲의 항소 받아들여 모든 청구를 판단했어야 함에도 불복 대상이 없다고 항소각하한 항소심법원

판단은 부당.

***선결논점으로 탈퇴 의의취지 및 요건이 아닌 참가승계 의의취지 및 요건을 적어도 무방

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 원본제출원칙과 예외

(1) 원본제출원칙 – 제355조

(2) 예외 – 사본제출

3. 사본의 증거조사

(1) 사본을 원본에 갈음하여 제출

(2) 사본을 원본으로 제출

(3) 사안 – 사본에 대해 乙이 부지로 다투었으므로 사본을 원본으로 제출

4. 사본의 증거능력 – 인정

5. 사본의 증거력

(1) 형식적 증거력

(2) 실질적 증거력

(3) 사안 – 사본에 대해 乙이 부지로 다투었는데, 구체적 증거 없이 변론의 전취지 만으로 원본의 존재와 진정성립을 인정한 것은 위법.

6. 사안해결

사본이 원본으로 제출되었고, 구체적 증거 없이 변론의 전취지만으로 원본의 존재와 진정성립을 인정한 것은 위법.

***지엽적인 논점이나, 최신判例 2023다217534가 6월에 있어 최종정리강의로 구체적 설명.

***지엽적인 논점이나, 기본서 내용 그대로 바르면 되는 쉬운 문제.

Ⅲ. 설문(3)

1. 문제의 소재

2. 중복소제기금지원칙 의의취지 및 요건

(1) 의의 및 취지 [제259조]

(2) 요건 - 계당소

(3) 사안 - 전소 계속 중, 동일 당사자 요건 만족하므로, 전소와 후소의 소송물이 동일한지 여부 검토하여 후소의 취급을 논함.

3. 소송물 동일 여부

(1) 사해행위취소소송의 의의 및 취지

(2) 피보전채권을 달리하는 경우 소송물 동일 여부

1) 사해행위취소소송의 소송물 - 사해행위취소 및 원상회복청구

2) 判例

(2) 사안 - 전후소는 소송물 동일

4. 사안해결

법원은 전소를 심리하고 후소로 제기된 사해행위취소소송을 중복소제기를 이유로 소각하 판결함.

***전소 계속 중이라고 문제에서 전제를 주었으므로 전후소 판단기준 기재할 실익 낮음.

<문제-2>

I. 설문(1) - 객준형 실전GS A형 1회 [문제-4] 출제

1. 문제의 소재

2. 대표권의 소송법상 의의 - 직권조사사항인지 여부

(1) 제64조

(2) 직권조사사항인지 여부 - 判例

(3) 사안 - 법원은 대표권 있는지 의심할 사정이 있었다면 이에 관해 심리, 조사할 의무가 있음

3. 대표권 흠결로 소각하시 지적의무 행사 요부

(1) 지적의무 의의 및 취지 [제136조 4항]

(2) 지적의무 요건

(3) 判例 - 2021다276973

(4) 사안 - 법원은 대표권 있는지 의심할 사정이 있었고, 대표자 지위에 관해 다툰 적 없고 주장, 증명도 하지 않았으므로 지적의무 행사했어야 함.

4. 사안해결

대표권을 직권으로 조사해보고 지적의무 행사하여 명확히 했어야 함에도 이에 이르지 않고 대표권 흠결로 소각하한 항소심법원 판단 부당.

***최신判例 2021다276973 사안이 사실관계 그대로 출제된 문제

***표시정정신청을 추인으로 볼 수 있는지 여부는 서브 논점으로 간략히 추가 가능. 단순히 표시정정신청서만 제출했다고 문제가 주어진 것이 아니라 당사자가 직접 추인 취지라고 주장하였으므로 추인으로 볼 수 있다고 간단히 언급만 하면 됨.

Ⅱ. 설문(2) - 객준형 실전GS A형 1회 [문제-2](추인의 소급효), 객준형 실전GS B형 4회 [문제-3](변론종결시 이후 소송요건 흠결 치유), 객준형 실전GS B형 5회 [문제-1](소각하한 원심판결에 원고만 불복시 청구기각 가부)

1. 문제의 소재

2. 중중총회결의 없이 제기된 소의 적법성

(1) 判例 - 2010다97044

(2) 사안 - 소송요건 흠결로 부적법

3. 소송요건의 판단 시점

(1) 원칙 - 변론종결시

(2) 예외 - 변론종결시 후 소송요건 흠결의 치유(2007다63362)

(3) 사안 - 변론종결시 이후 적법한 임시총회를 통해 소송요건 흠결을 추인하는 참고자료 제출하였으므로 상고심은 이를 기초로 판단 가능

4. 추인으로 인한 소송요건 흠결 치유

(1) 추인 의의 및 취지

(2) 추인 효과 - 소급효

(3) 사안

5. 사안해결 - 상고심판결

(1) 원심판결의 파기 - 추인의 소급효가 인정되므로 소각하판결 파기

(2) 환송(원심에서 충분히 심리되지 않았다고 보는 경우) or 재판(원심에서 충분히 심리되었다고 보는 경우) 항소심 입장에서 재판하여 1심 청구기각판결을 지지하는 항소기각, 단, 2018다227087 판시에선 불이익변경금지를 들며 소각하보다 불리한 청구기각 할 수 없다며 상고기각, 이 경우 "소원기" 학판검 기재)

***환송 또는 재판 중 어느 쪽으로 결론을 내려도 무방

***소각하 판결에 원고만 불복한 경우 청구기각판결 가부, 일명, "소원기" 학판검의 기재 요부와 관련하여 보면, 상고심이 이미 사건이 충분히 심리되었다면 항소심 입장에서 재판하여 1)항소각하, 2)항소기각, 3)항소인용(or1심취소)하여 소각하/청구기각/청구인용 중 하나의 결론을 내려야 함. 여기서, 이미 충분히 심리된 내용대로 결론을 내리자면 청구기각의 결론을 내려야 할 것인데, 1심판결로 청구기각이 이미 있으므로 상고심이 항소심 입장에서 판결할 때는 1심 청구기각을 지지해주는 "항소기각"판결 가능. 수업시간에 설명드린 상고심의 판결방법에 대한 도해를 떠올려 보면 좋음.

단, 2018다227087 판시에선 불복한 원고에게 더 불리한 판결을 할 수 없다는 이유로 상고기각함. 따라서, "소원기"논점을 적더라도 득점 가능.

<문제-3>

1. 설문(1) - 객준형 실전GS A형 6회 [문제-3] 출제

1. 문제의 소재

2. 상소심 이심 범위

(1) 상소불가분원칙

(2) 사안 - 원고가 패소한 4천만 원에 대해 불복했더라도 전체 1억 원 모두 확정차단되고 상소심으로 이심됨.

3. 상소심 심판대상

(1) 불이익변경금지원칙 의의 및 취지 [제415조]

(2) 불이익변경금지원칙 판단기준

(3) 불이익변경금지원칙 예외 - 상처소상필 [제415조 단서]

(4) 사안 - 원고만 불복했지만 항소심에서 상계주장은 불변금의 예외이므로 원고에게 더 불이익하게 4천만 원 인용 가능

4. 사안해결

항소심으로 전부 이심되고 항소심에서 상계주장으로 인해 항소인에게 불이익하게 판단 가능하므로 항소심법원 판단은 타당.

***주장 판단순서의 간략한 언급도 가능하나 변제주장이 모두 이유 없다고 하였으므로 기재실익은 낮음.

***배점이 주어진 논점에 다소 크므로 의의, 취지, 판단기준 등 일반론을 좀 더 펼쳐서 기재.

II. 설문(2) - 객준형 실전GS A형 8회 [문제-2] 출제

1. 문제의 소재

2. 소취하의 효력 발생 여부

(1) 소취하 의의 및 취지 [제266조]

(2) 소취하 요건 충족 여부 - 판결 확정 전, 상대방 동의

(3) 소취하 효과 - 소송 소급소멸

3. 착오 소취하를 민법 유추하여 무효, 취소 주장 가부

(1) 문제점 - 여효적 소송행위의 성질

(2) 학판검

(3) 사안 - 착오 소취하를 민법 유추하여 무효, 취소 주장 不可

4. 사안해결 - 법원의 조치

(1) 기일지정신청 의의 및 취지, 취급

(2) 기일지정신청 기각 및 소송종료선언

***소취하에 대한 상대방 동의도 문제 문구로 주어졌으므로 소취하 요건, 효과 선결로 언급.

***재심규정 유추는 단순 착오가 아니라 타인의 처벌받을 행위로 소송행위가 이루어진 경우 문제 되므로 기재실익 낮음.

Ⅲ. 설문(3) – 메가 모의고사 [문제-3] 출제

1. 문제의 소재

2. 자백 의의, 취지 및 효과

(1) 의의 및 취지

(2) 효과 – 제288조, 법원 및 당사자 구속

3. 소유권에 대한 자백 인정 여부

(1) 문제점 – 권리자백

(2) 학판검

(3) 사안 – 소유사실 인정하는 자백으로 인정 가능

4. 사안해결

乙자백에 따라 甲의 소유사실을 인정하는 것으로 판단해야 함.

***“甲이 주장하는 소유권”이라고 문제에서 주어져 있으므로 선행자백은 논점 아님.

***권리자백에 대한 일반론 간단히 언급 가능.

<문제-4>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 소송행위 추후보완 의의 및 취지 [제173조 1항]

3. 추후보완 요건

(1) 불변기간 – 항소기간은 제396조의 불변기간

(2) 책임질 수 없는 사유

1) 책임질 수 없는 사유 판단기준 - 처음부터 공시송달 원칙 判例 or 소송 도중 공시송달 원칙 判例

2) 사안 - 조정불성립으로 소송으로 이행된 후 발송송달, 공시송달된 경우 책임질 수 없는 사유를 구체적으로 판단 要

4. 조정불성립으로 소송으로 이행되어 발송송달, 공시송달된 경우

(1) 判例 - 2015다213322

(2) 사안 - 책임질 수 없는 사유 인정

5. 사안해결

乙이 판결정본이 공시송달된 것을 안 시점이 불분명하나, 기간준수 했다는 전제 하에 불변기간 미준수에 대한 책임질 수 없는 사유 인정하여 추후보완항소 허용했어야 하므로 부당

***일반론으로 책임질 수 없는 사유의 원칙적 판단기준 判例를 선결로 제시해줌이 바람직.

***발송송달, 공시송달에 특별한 하자가 있다고 보기는 어려움.

***추후보완 기간준수 판단기준(2주, 공시송달)도 써줄 수 있으나, 문제에서 이에 관해 주어진 사실관계가 없으므로 써주더라도 약간만 씀.

***다소 지엽적인 判例, 만약 이런 지엽적인 判例를 몰랐다면 문제의 물음이 추후보완의 허용 여부를 묻고 있으므로 1)추후보완 요건을 중심축으로 삼아 기재하면서 2)주로 문제되는 요건인 책임질 수 없는 사유 존부를 "문제 사실관계"를 근거로 들어주면서 결론을 내렸다면, 설령 답이 틀려 일부 감점이 있더라도 기본점수는 가져감(항상 기본기에 충실한 것이 중요).

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 공시송달의 효력

(1) 공시송달의 의의 및 취지 [제194조]

(2) 공시송달의 효력 - 위법하지만 유효(2019다220618)

2. 소송행위 추후보완 의의 및 취지 [제173조 1항]

3. 추후보완 요건

(1) 불변기간 - 항소기간은 제396조의 불변기간

(2) 책임질 수 없는 사유

1) 책임질 수 없는 사유 판단기준 - 소송 도중 공시송달 원칙 判例 및 예외 判例(2019다 220618)

2) 사안 - 책임질 수 없는 사유 인정

4. 추후보완 절차

(1) 기간준수 판단 원칙

(2) 공시송달의 경우

1) 기산점 - 判例

2) 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때의 의미 - 判例

3) 사안 - 22.8.22. 판결정본 영수로 판결이 공시송달된 것을 알았고, 그로부터 2주 이내인 22.9.2. 추후보완항소하여 기간준수 인정

5. 사안해결

불변기간 미준수에 책임질 수 없는 사유 인정되고 기간준수하였으므로 추후보완항소 부적법하다고 한 항소심법원 판단에 위법이 있음

***최신判例 2019다220618 사안이 사실관계 그대로 출제된 문제.

***설문(1)과 마찬가지로 추후보완 파트의 요건, 절차에 해당하는 기본 判例를 윤곽에 맞춰 현출해주고 차근차근 풀어주면 되는 문제.

***발송송달에 대해서 논해주는 것은 주논점 아님, 공시송달에 대해서도 判例대로 간략히 위법하지만 유효하다고 기재하면 족함.